

1500583-31.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... agente penitenciário. No tocante ao tráfico de drogas, narrou que o denunciado desconhecia a existência dos entorpecentes no interior da mochila (ausência de dolo). Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da confissão espontânea do delito previsto no art. 349-A, do Código Pena. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de entorpecentes (art. 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe-SP - cep 12120-013

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500583-31.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500583-31.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2120590/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 24728485 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2120590 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2120590 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALISSON SAMUEL DE LIMA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia ALISSON SAMUEL DE LIMA SANTOS, como incurso(s) na prática do(s) delito(s) tipificado(s) nos artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da LEI Nº 11.343/2006, bem como pelo art. 349-A, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 04 de maio de 2022, por volta da 01h, na Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha", situada na Rodovia Amador Bueno da Veiga, km 138, Bairro do Una, nesta cidade e comarca, ALISSON SAMUEL DE LIMA SANTOS¹, qualificado a fls. 04, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, 92,06g de Cannabis sativa L (maconha), sem autorização ou em desacordo com regulamentação legal ou

regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão a fls. 14/15 e laudo de constatação provisória a fls. 18/19.

Consta, também, que, na mesma data e local, ALISSON SAMUEL DE LIMA SANTOS promoveu a entrada de 61 aparelhos telefônicos de comunicação móvel², sem autorização legal, no mencionado estabelecimento prisional.

Segundo se apurou, indivíduos não identificados contrataram o denunciado para arremessar drogas e celulares ao interior da Penitenciária “Dr. Edgard Magalhães Noronha”, conduta de criminosos popularmente conhecidos neste Município como “ninjas”.

Então, na madrugada dos fatos, o indiciado, na posse de uma mochila contendo uma porção da maconha, 61 aparelhos celulares, 61 carregadores de celular, 16 baterias e 09 cabos USB, dirigiu-se à unidade prisional e pulou o muro.

No entanto, Agentes de Segurança Penitenciária surpreenderam ALISSON entre a “linha de tiro” e a portaria do presídio.

Interrogada, exerceu seu direito constitucional de permanecer silente (fls.4).

Denúncia recebida em 06 de maio de 2022 (fls. 54).

O acusado ofereceu Defesa prévia (fls. 55/64).

Em audiência de Instrução e Julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais de forma orais, devidamente registradas na mídia da audiência.

Em síntese, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, nos exatos termos em que formulada.

A defesa pugnou pela absolvição do denunciado, tendo em vista que não houve a oportunidade de consumir o delito (crime impossível), pois logo foi detido pelo agente penitenciário. No tocante ao tráfico de drogas, narrou que o denunciado desconhecia a existência dos entorpecentes no interior da mochila (ausência de dolo). Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da confissão espontânea do delito previsto no art. 349-A, do Código Pena. Subsidiariamente, pediu o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de entorpecentes (art. 33, §4º, da lei 11.343/06). Pediu, ainda, o reconhecimento da atenuante de pena pela menoridade relativa do réu.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público Estadual imputando ao denunciado ALLISON SAMUEL DE LIMA SANTOS, já qualificado, os delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, III da lei 11.343/06 e art. 349-A, do Código Penal. O feito encontra-se em ordem.

Não há preliminares a dirimir.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no art. artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e art. 349-A, do Código Penal.

DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06.

Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade restou demonstrada pelo: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 05/07), Auto de exibição/apreensão (fl.14/15), Laudo provisório de entorpecentes (fls. 17/19), Laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 95/97), bem como pela prova oral coligida durante a instrução.

A autoria, por sua vez, é incontestada, restou-se demonstrada através da prova oral colhida tanto em solo policial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa.

Em Juízo, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Geraldo David de Campos Neto, agente penitenciário, o qual relatou que:

Estava fazendo ronda de rotina. Pegou o denunciado pulando o muro para ingressar no estabelecimento. Avistou um vulto entre a portaria e o jardim, que fica em frente a portaria. Localizou o denunciado, que alegou disse que foi contratado para levar a mochila e que iria ganhar 2 mil reais para isso, mas que não sabia o conteúdo da mochila. O denunciado já havia pulado o muro, o próximo passo seria para passar o alambrado para então jogar a mochila.

Em resposta às indagações feitas pela representante do Ministério Público, disse que: O denunciado já havia transposto o muro, estava próximo ao alambrado. É frequente esse tipo de coisa. Os ninjas se aproximam para tentar arremessar. É corriqueiro. Geralmente são celulares e drogas, é o que mais se encontra ali.

Em resposta às indagações feitas pela defesa, disse que:

O denunciado já tinha pulado o muro quando o avistou, já estava entre o muro e o alambrado. O muro tem por volta de 2, 2,5 metros de altura. A distância entre o muro e o alambrado deve dar uns 5 metros. O alambrado possui uns 3 a 5 metros de altura. Não possui câmeras. É um presídio de semiaberto. Conteve o Alisson.

Conforme o denunciado narrou, ele estava em contato por telefone com um preso lá dentro, pois ele não conhecia o estabelecimento e não sabia onde deveria entregar.

O denunciado disse que receberia 2 mil reais para arremessar a mochila, que não sabia o conteúdo da mochila. Disse que teria sido aliciado por uma mulher em São José dos Campos, essa mulher foi quem o levou até a entrada do estabelecimento. O denunciado não ofereceu qualquer tipo de residência. Solicitou apoio a outros funcionários. A mochila foi aberta na frente da portaria, perante outros funcionários. Não existe câmera no local, por se tratar de unidade semiaberto. A mochila foi aberta e sendo encontrados os itens, telefones celulares, carregadores, um pouco de droga que acredita ser maconha. Todos os objetos estavam dentro da mochila. Nada foi encontrado pessoalmente com o Alisson, tão somente na mochila.

Em Juízo, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Thiago Silva Santos, agente penitenciário, o qual relatou que:

Estava de plantão nesse dia. Tem dois pontos de cobertura, uma torre e uma base.

Estava na base, quando escutou via rádio, solicitando apoio na portaria. Pegou uma viatura e foi se deslocar. Ele ouviu no rádio uma indicação que havia alguém no coco. Quando ele chegou, o Geraldo já estava com a situação dominada. O denunciado já estava no chão. Ele apenas entregou as algemas. Levaram ele até a portaria.

Encontraram celulares, carregadores e uma porção de maconha.

Em resposta às indagações feitas pela representante do Ministério Público, disse que:

O acusado foi abordado ao lado da portaria, já dentro. Entre um alambrado e um muro. Entre a linha de tiro e a portaria do presídio. Entre um alambrado e outro. Ele já tinha transposto o muro. O denunciado disse que uma pessoa foi no bairro dele procurador por um menor de idade, ele estava perto, escutou, viu que era só para levar a mochila, achou fácil e tentou. Ia ganhar uma quantia de 2 mil reais. O denunciado não disse pra quem era. Ele disse que sequer sabia o que tinha na mochila. Apenas pegou a mochila já carregada e foi jogar no estabelecimento. Quando ele chegou, já estava deitado e a mochila esta ao seu lado. É uma coisa comum de acontecer no estabelecimento, pularem para jogar drogas no estabelecimento. São popularmente conhecidos como ninja, que vem para fazer os arremessos. Estou na penitenciária desde Janeiro. De Janeiro até hoje foram duas pessoas pegas fazendo esse tipo de conduta. Duas pessoas foram presas já no interior. Outras abordagens foram realizadas antes de conseguirem, ingressar no estabelecimento para arremessar. Duas foram presas. Não sabe dizer exatamente quantas pessoas foram pegas tentando. Algumas pessoas pulam o muro para arremessar enquanto outras que arremessam de fora mesmo. Não sabe exatamente quantas pessoas foram pagas, mas são muitas. Desde o momento que foi chamado no rádio, foi bem rápido, 5 a 10 minutos.

Em resposta às indagações feitas pela defesa, disse que:

Ele pulou o muro, depois seria o alambrado. Entre esse muro que ele pulou, até o alambrado, é uma distância de 7 a 10 metros. O primeiro alambrado é alto, o muro

também. Aproximadamente 10 metros. O muro é alto. Não avistou o momento que o denunciado foi detido, foi o Geraldo. Ele chegou em apoio, quando o denunciado já estava contido. O local é monitorado somente por pessoas, não conhece a existência de câmeras. De frente a este local, possui uma torre, onde fica um agente nela. O Geraldo é o diretor do plantão noturno, ele fica com o veículo fazendo rondas. Ele foi conduzido até a portaria, chegaram alguns diretores, de disciplina e o diretor geral da unidade. Eles abriram a mochila, no seu interior tinham vários pacotes, eles foram abrindo os pacotes. O denunciado disse a ele que não sabia o conteúdo da mochila.

O denunciado foi encontrado dentro do estabelecimento, entre o muro e o alambrado. Não foi ele que encontrou a droga, eram vários agentes, não sabe quem foi exatamente.

A informante Maria do Carmo, genitora do denunciado, narrou tão somente que seu filho havia saído de casa no período noturno e que não retornou. Na tarde do outro dia ela ficou sabendo da prisão do Allisson. Disse ainda que seu filho teria dito que aceitou fazer esse serviço pelo valor de 2 mil reais e que teria sido levado para o presídio para jogar a mochila. Disse que ele estuda, trabalha, tem namorada. Disse que seu filho contou a ela que aceitou o serviço pelo dinheiro.

Em seu interrogatório, o réu Alisson Samuel de Lima Santos, declarou que:

Confessou que pulou o muro, pois estava passando dificuldades financeiras. Era 2 mil reais, somente para jogar a mochila. Uma mulher o levou até o presídio. A mochila tinha carregadores e celulares, negou a existência da droga. Quando ele pulou o muro, via uma viatura correndo. Deitou no chão e se entregou. Disse que não tinha droga na mochila e que a droga teria sido implantando pelos agentes penitenciários para prejudicá-lo. Disse que precisava do dinheiro para ajudar em casa, pois estavam passando necessidades. Confirmou desconhecer a existência da droga, disse que sabia que tinha telefones e carregadores, negou que tinha qualquer droga.

Nota-se que ambas as testemunhas prestariam firme depoimento vinculando o acusado às drogas apreendidas.

Aos depoimentos dos agentes penitenciários deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição ou com o objetivo de incriminar dolosamente o réu.

Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015).

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos agentes penitenciários que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos.

E no caso, as testemunhas agentes penitenciários, ouvidas em juízo, asseveraram ter sido o denunciado flagrado na posse de uma mochila, depois de pular o muro do interior do estabelecimento penal, próximo ao alambrado. Dentro dessa mochila foi encontrada a substância entorpecente, devidamente apreendida (fls. 14/15) e periciada (fls. 17/19 e 95/97).

Se mostra pouco convincente a versão apresentada pelo acusado ALISSON, de que a droga apreendida não estava na mochila, mas sim que foi plantada pelos agentes penitenciários responsáveis pela sua prisão. Para ter a versão apresentada pelo

acusado CLEITON como verdadeira este juízo deveria descartar totalmente a firme e harmoniosa versão apresentada pelas DUAS testemunhas ouvidas em juízo, o que vai de encontro com todo o entendimento jurisprudencial firmado neste Tribunal de Justiça, bem como no âmbito da Corte Superior de Justiça, cujo entendimento é uníssono em que se deve dar total relevância ao depoimento apresentado pelos agentes públicos responsáveis pelo flagrante e apreensão, porque esses, na qualidade de agentes da lei, gozam de especial credibilidade e presunção de veracidade em seus relatos, especialmente quando estão em harmonia e consonância com as demais provas produzidas, o que é justamente o caso dos autos.

Ademais, ao contrário do mencionado pela defesa, não há nada nos autos, além do vazio depoimento do réu, que possa colocar em dúvida a versão firme e uníssona apresentadas pelos agentes públicos ouvidos em juízo, devidamente compromissados com o dever de dizer a verdade.

Trata-se, em verdade, de tentativa totalmente descabida de esquivar da responsabilidade penal.

Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos agentes que atuaram no caso sub judice.

Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos.

A prova produzida nos autos é segura e conclusiva, sendo apta a autorizar o decreto condenatório.

Quanto ao tráfico de drogas, analisados os aspectos referidos, que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, é evidente que a droga encontrada no caso em questão destinava-se a mercancia ilícita, mormente pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como pela forma e local onde foram encontrados os entorpecentes, o que afastam qualquer tese de ser mero usuário de entorpecentes.

Cabe citar que a venda propriamente dita da droga não é elemento indispensável para a configuração da traficância, tendo em vista consistir o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) em tipo penal misto alternativo, bastando, para a configuração do aludido delito, a prática de qualquer uma das 18 ações tipificadas (importar, exportar, remeter preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), dispensada a prova do ato da mercancia em si, perfilhando desse mesmo entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO INTERNACIONAL DROGAS. EXPORTAR OU REMETER DROGA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 528. (...) O crime de tráfico de drogas é considerado de ação múltipla ou tipo misto alternativo, em que a consumação ocorre com a incidência de qualquer dos núcleos. (STJ, CC 146.393/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJ e 01/07/2016)

TÓXICO Crime de tráfico Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito Depoimentos de agentes policiais Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas Análise que se faz em cada caso concreto Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório Policial que se diz usuário Flagrante legal Tipo penal misto alternativo que dispensa a prova da conduta da venda para a prisão e acusação Condenação mantida Pena correta e adequada ao caso Regime fechado mantido Recurso improvido (TJSP, Relator (a): Newton Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015).

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a espécie da substância entorpecente apreendida, a forma como acondicionada, as circunstâncias do flagrante, tornam evidente que a droga destinava-se ao consumo de terceiros. Tais

circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Em suma, todos os elementos de convicção compilados nos autos efetivamente indicam que a droga apreendida destinava-se ao tráfico.

Ademais, a tese formulada pela defesa de se tratar de crime impossível não prevalece.

O crime impossível é definido pelo art. 17, do Código Penal:

Crime impossível (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 17 - Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

No caso dos autos, como já fundamentado acima, o crime de tráfico de entorpecentes não se exige a efetiva entrega a terceiros para configurar sua consumação, exigindo tão somente alguma das figuras previstas no art. 33, da lei 11.343/06, o que se afigura presente, uma vez que o denunciado foi flagrado na posse da substância entorpecente, já tendo o delito efetivamente se consumado.

O dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o acusado era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o acusado, de forma deliberada, estava na posse de substâncias entorpecentes descritas no laudo químico-toxicológico de fls. 95/97, sem a devida autorização, não restando qualquer dúvida a respeito do caráter consciente da conduta.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga, comportamento do representado logo antes ou no momento da apreensão, a existência de outros elementos referentes à venda, etc.

Nesta senda:

"A natureza altamente lesiva e a quantidade de porções da droga capturada, somadas à apreensão de apetrechos geralmente utilizados no preparo e disseminação de tóxicos, bem como de certa quantia em dinheiro, são fatores que indicam envolvimento maior com a traficância, autorizando à preventiva." (HC 323.748/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2015, REPDJ e 05/10/2015, DJ e 28/09/2015).

Quanto ao destino das droga apreendidas, não se discute que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao nefando tráfico. A diversidade das drogas apreendidas, a maneira como estavam acondicionadas, bem como a as condições de tempo e lugar em que o acusado foi abordado, além das declarações dos policiais, denunciam o referido comércio.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Tendo em vista que o delito foi praticado no interior do estabelecimento penitenciário "Dr. Edgard Magalhães Noronha" - Penitenciária de Tremembé, presente está a causa de aumento de pena previsto no art. 40, III, da lei 11.343/06.

Dessa forma, mister se faz a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06.

DA IMPUTAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 349-A, DO CÓDIGO PENAL

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostadas aos autos inúmeras provas, todas elas convergentes e unidirecionais no de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Vejamos.

A autoria, por sua vez, é inconteste, restou-se demonstrada através da prova oral colhida tanto em solo policial quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em Juízo, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Geraldo David de Campos Neto, agente penitenciário, o qual relatou que:

Estava fazendo ronda de rotina. Pegou o denunciado pulando o muro para ingressar no estabelecimento. Avistou um vulto entre a portaria e o jardim, que fica em frente a portaria. Localizou o denunciado, que alegou disse que foi contratado para levar a mochila e que iria ganhar 2 mil reais para isso, mas que não sabia o conteúdo da mochila. O denunciado já havia pulado o muro, o próximo passo seria para passar o alambrado para então jogar a mochila.

Em resposta às indagações feitas pela representante do Ministério Público, disse que: O denunciado já havia transposto o muro, estava próximo ao alambrado. É frequente esse tipo de coisa. Os ninjas se aproximam para tentar arremessar. É corriqueiro. Geralmente são celulares e e drogas, é o que mais se encontra ali.

Em resposta às indagações feitas pela defesa, disse que:

O denunciado já tinha pulado o muro quando o avistou, já estava entre o muro e o alambrado. O muro tem por volta de 2, 2,5 metros de altura. A distância entre o muro e o alambrado deve dar uns 5 metros. O alambrado possui uns 3 a 5 metros de altura. Não possui câmeras. É um presídio de semiaberto. Conteve o Alisson.

Conforme o denunciado narrou, ele estava em contato por telefone com um preso lá dentro, pois ele não conhecia o estabelecimento e não sabia onde deveria entregar.

O denunciado disse que receberia 2 mil reais para arremessar a mochila, que não sabia o conteúdo da mochila. Disse que teria sido aliciado por uma mulher em São José dos Campos, essa mulher foi quem o levou até a entrada do estabelecimento. O denunciado não ofereceu qualquer tipo de residência. Solicitou apoio a outros funcionários. A mochila foi aberta na frente da portaria, perante outros funcionários. Não existe câmera no local, por se tratar de unidade semiaberto. A mochila foi aberta e sendo encontrados os itens, telefones celulares, carregadores, um pouco de droga que acredita ser maconha. Todos os objetos estavam dentro da mochila. Nada foi encontrado pessoalmente com o Alisson, tão somente na mochila.

Em Juízo, foi ouvida a testemunha arrolada pelo Ministério Público, Thiago Silva Santos, agente penitenciário, o qual relatou que:

Estava de plantão nesse dia. Tem dois pontos de cobertura, uma torre e uma base. Estava na base, quando escutou via rádio, solicitando apoio na portaria. Pegou uma viatura e foi se deslocar. Ele ouviu no rádio uma indicação que havia alguém no coco. Quando ele chegou, o Geraldo já estava com a situação dominada. O denunciado já estava no chão. Ele apenas entregou as algemas. Levaram ele até a portaria. Encontraram celulares, carregadores e uma porção de maconha.

Em resposta às indagações feitas pela representante do Ministério Público, disse que:

O acusado foi abordado ao lado da portaria, já dentro. Entre um alambrado e um muro. Entre a linha de tiro e a portaria do presídio. Entre um alambrado e outro. Ele já tinha transposto o muro. O denunciado disse que uma pessoa foi no bairro dele procurador por um menor de idade, ele estava perto, escutou, viu que era só para levar a mochila, achou fácil e tentou. Ia ganhar uma quantia de 2 mil reais. O denunciado não disse pra quem era. Ele disse que sequer sabia o que tinha na mochila. Apenas pegou a mochila já carregada e foi jogar no estabelecimento. Quando ele chegou, já estava deitado e a mochila esta ao seu lado. É uma coisa comum de acontecer no estabelecimento, pularem para jogar drogas no estabelecimento. São popularmente conhecidos como ninja, que vem para fazer os arremessos. Estou na penitenciária desde Janeiro. De Janeiro até hoje foram duas pessoas pegadas fazendo esse tipo de conduta. Duas pessoas foram presas já no interior. Outras abordagens foram realizadas antes de conseguirem, ingressar no estabelecimento para arremessar. Duas foram presas. Não sabe dizer exatamente quantas pessoas foram pegadas tentando. Algumas pessoas pulam o muro para arremessar enquanto outras que arremessam de fora mesmo. Não sabe exatamente quantas pessoas foram pagas, mas são muitas. Desde o momento que foi chamado no rádio, foi bem rápido, 5 a 10 minutos.

Em resposta às indagações feitas pela defesa, disse que:

Ele pulou o muro, depois seria o alambrado. Entre esse muro que ele pulou, até o alambrado, é uma distância de 7 a 10 metros. O primeiro alambrado é alto, o muro também. Aproximadamente 10 metros. O muro é alto. Não avistou o momento que o denunciado foi detido, foi o Geraldo. Ele chegou em apoio, quando o denunciado já estava contido. O local é monitorado somente por pessoas, não conhece a existência

de câmeras. De frente a este local, possui uma torre, onde fica um agente nela. O Geraldo é o diretor do plantão noturno, ele fica com o veículo fazendo rondas. Ele foi conduzido até a portaria, chegaram alguns diretores, de disciplina e o diretor geral da unidade. Eles abriram a mochila, no seu interior tinham vários pacotes, eles foram abrindo os pacotes. O denunciado disse a ele que não sabia o conteúdo da mochila.

O denunciado foi encontrado dentro do estabelecimento, entre o muro e o alambrado. Não foi ele que encontrou a droga, eram vários agentes, não sabe quem foi exatamente.

A informante Maria do Carmo, genitora do denunciado, narrou tão somente que seu filho havia saído de casa no período noturno e que não retornou. Na tarde do outro dia ela ficou sabendo da prisão do Allisson. Disse ainda que seu filho teria dito que aceitou fazer esse serviço pelo valor de 2 mil reais e que teria sido levado para o presídio para jogar a mochila. Disse que ele estuda, trabalha, tem namorada. Disse que seu filho contou a ela que aceitou o serviço pelo dinheiro.

Em seu interrogatório, o réu Allisson Samuel de Lima Santos, declarou que:

Confessou que pulou o muro, pois estava passando dificuldades financeiras. Era 2 mil reais, somente para jogar a mochila. Uma mulher o levou até o presídio. A mochila tinha carregadores e celulares, negou a existência da droga. Quando ele pulou o muro, via uma viatura correndo. Deitou no chão e se entregou. Disse que não tinha droga na mochila e que a droga teria sido implantando pelos agentes penitenciários para prejudicá-lo. Disse que precisava do dinheiro para ajudar em casa, pois estavam passando necessidades. Confirmou desconhecer a existência da droga, disse que sabia que tinha telefones e carregadores, negou que tinha qualquer droga.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

Com efeito, os agentes de segurança penitenciária GERALDO e THIAGO narraram os fatos com riqueza de detalhes, de forma uníssona e coerente, nada indicando que compareceram em Juízo com o único intuito de prejudicar alguém que soubessem ser inocente.

O art. 349-A, do Código Penal, tipifica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada em estabelecimento prisional de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar.

Ademais observa-se que a conduta praticada pelo acusado alcançou a consumação do delito, posto que ele ingressou no referido estabelecimento prisional em posse da mochila contendo os aparelhos de telefone celular e carregadores, mencionados no auto de exibição a apreensão de fls. 14/15.

As teses defensivas tratam de questões concernentes à dosimetria da pena, de modo que serão analisadas em momento oportuno.

Dessa forma, mister se faz a condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 349-A, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, analisando detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, bem como o art. 42, da lei 11.343/06 observo que o acusado é primário e não porta maus antecedentes. Merece valoração negativa, no tocante especificamente às circunstâncias do crime previsto no art. 349-A, do CP, o fato de que em poder do réu foram apreendidos 61 aparelhos de telefone celular e 61 carregadores. Trata-se de elevadíssima quantidade que pode provocar efeitos nefastos não só a organização penitenciária mas também à sociedade, uma vez que é cediço que muitos presos exercem posição de liderança no crime organizado, e que efetivamente ordenam, inclusive, a prática de graves crimes no exterior do estabelecimento. No mais, as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, bem como art. 42, da lei 11.343/06 são normais à espécie de delito. Dessa forma, fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, para o delito tipificado no art. 33, caput, da lei 11.343/06 e 4 (quatro) meses de detenção pelo delito do art. 349-A, do CP.

Na segunda fase, anoto estar presente a circunstância atenuante da menoridade

relativa (art. 65, I, do CP), tendo em vista que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. Além disso, no tocante ao delito previsto no art. 349-A, do CP, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Contudo, inviável, nos termos da súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que as penas fiquem aquém do seu mínimo legal. Dessa forma, presente a atenuante, torno as penas ao patamar mínimo legal.

Na terceira fase, especificamente em relação ao delito de tráfico, presente está a causa de aumento de pena de pena prevista no art. 40, III, da lei 11.343/06, tendo em vista que o réu foi flagrado na posse das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 14/15) e periciadas (fls. 95/97) no interior do estabelecimento penitenciário. Não havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade, fixo a causa de aumento no mínimo legal de 1/6, fixando a pena para o delito do art. 33, caput, da lei 11.343/06 em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na derradeira e última fase, anoto ser inviável a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do Código Penal, uma vez que o denunciado registra antecedentes no meio infracional justamente por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes (fls. 29). Os requisitos previstos no art. 33, §4º, quais sejam primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa são CUMULATIVOS, de modo que para a acusada fazer jus a tal causa de diminuição de pena, devem estar presente todos os requisitos, o que não é o caso.

Há pouco menos de 1 (um) ano o réu, então adolescente, foi apreendido em flagrante ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo a representação formulado pelo MP julgada procedente para cumprimento de medida em meio aberto (autos 1501796-35.2021.8.260577). Além disso, o mesmo adolescente foi flagrado na posse de arma de fogo sem a devida autorização, representação que somente foi arquivada pelo fato do adolescente ter sido condenado nos autos acima mencionados, perdendo, assim, o interesse de agir nesta representação. Tudo isso conforme consta de sua certidão de antecedentes infracionais (fls. 29).

Por conseguinte, observo que, apesar da primariedade criminal e da ausência de maus antecedentes, o réu, mesmo que em tenra idade, já faz das atividades criminosas seu meio de vida, podendo se concluir não se tratar do traficante meramente eventual, mas sim de pessoa que faz do crime seu meio de vida, restando afastada, assim, a minorante prevista do art. 33, §4º, da lei 11.343/06, por ficar evidenciado a dedicação a atividades criminosas.

Cumprе salientar que este entendimento é corroborado pela jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, bem como por precedentes da Corte Superior:

TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais militares corroborados pela confissão parcial do réu. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Pena que não comporta alteração. Redutor afastado em razão da prática de ato infracional análogo ao tráfico quando adolescente. Jurisprudência do E. STJ. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1501560-80.2020.8.26.0363; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Mirim - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias ordinárias ? dentro do seu livre convencimento motivado ? apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a

atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".

5. A Corte de origem justificou a fixação do regime inicial mais gravoso com base nas peculiaridades do caso concreto ? notadamente na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nos registros infracionais anteriores ? elementos que, de fato, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 698.311/SP, relator Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/5/2022.)

Dessa forma, , fixo a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, para o delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da lei 11.343/06 e 3 (três) meses de detenção, para o delito tipificado no art. 349-A, do CP.

Considerando que o acusado é tecnicamente primário e pela quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento da pena do delito de tráfico e ABERTO em relação ao delito do art. 349-A, do CP, consoante determina o art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração para fins de fixação do regime prisional, haja vista que perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena; confusão que viola os princípios de individualização penal, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal.

O valor de cada dia-multa será no mínimo legal de 1/30 ao salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em razão das limitadas condições econômicas dos réus (art. 43, da Nova Lei de Drogas).

Ante o montante de pena aplicada, inviável a substituição da pena (art. 44, do CP), bem como a suspensão (art. 77, do CP).

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia para CONDENAR o réu ALISSON SAMUEL DE LIMA SANTOS, qualificado aos autos, pelo delito tipificado no artigo 33, caput, da LEI Nº 11.343/2006, a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)

meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime inicial SEMIABERTO e no art. 349-A, do Código Penal, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial ABERTO.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Cumpre salientar que após estabelecer o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena após condenação, a negativa do direito do sentenciado de recorrer em liberdade deve ser compatível com as condições do regime determinado. Fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. Dessa forma, não há como se compatibilizar a prisão preventiva do acusado com a fixação do regime inicial diverso do fechado, mormente quando as circunstâncias do caso concreto não permitam concluir pela presença de nenhum dos fundamentos autorizadores da decretação da custódia cautelar máxima. Dessa forma, concede ao réu liberdade provisória cumulada com a medida cautelar diversa da prisão de: a) proibição de ausentar-se da comarca em que reside por mais de 10 (dez) dias sem comunicação ao juízo e b) proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares que impostas poderá resultar na decretação da prisão preventiva.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em favor da União.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06;

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Tremembe, 14 de julho de 2022.

MARGEM DIREITA